

1503768-66.2022.8.26.0266

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho

Comarca: Itanhaém

Foro: Foro de Itanhaém

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO GUERRA ANTONIO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho

VISTOS

GUSTAVO GUERRA ANTONIO, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público, valendo-se da atribuição que lhe é conferida pelo artigo 129, inciso I, da Constituição ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itanhaém

Foro de Itanhaém

1ª Vara

Avenida Rui Barbosa, 867, Itanhaém-SP - cep 11740-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503768-66.2022.8.26.0266 - lauda

CONCLUSÃO

Aos 18/11/2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Judicial, Exmo. Sr. Dr. PAULO ALEXANDRE RODRIGUES COUTINHO. Eu, _____, subscrevi.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503768-66.2022.8.26.0266

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO GUERRA ANTONIO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho

VISTOS

GUSTAVO GUERRA ANTONIO, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público, valendo-se da atribuição que lhe é conferida pelo artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pela prática dos fatos delituosos narrados na introital de fls. 01/02, in verbis:

"Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 17 de agosto de 2022,

por volta da 20h24, na rua Manoel F. Lisboa, em um beco na altura do imóvel nº 65, Chácara das Tâmaras, bairro Belas Artes, neste município e comarca de Itanhaém, GUSTAVO GUERRA ANTÔNIO, qualificado à fl. 06, trazia consigo 97 porções de Cannabis sativa L, 455 pedras de crack, 137 papelotes de cocaína e 04 frascos contendo Cannabis sativa L hidropônica, drogas destinadas à venda, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo apurado, o denunciado trazia consigo as drogas acima descritas, dentro de uma sacola e de sua mochila, destinadas à venda, contudo, ao perceber a aproximação de policiais militares, tentou fugir, seguindo-se a prisão em flagrante, a apreensão dos entorpecentes e do valor de R\$ 86,00, fruto do tráfico ilícito."

Acompanhou a denúncia o auto de prisão em flagrante, no qual, estando em termos, foram juntados, dentre outros documentos, termos de declarações, o boletim de ocorrência (fls.11/13), o auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), o auto de constatação prévia de entorpecente (fls.16/17), a nota de culpa (fl.23) e o relatório lavrado pela Polícia Judiciária (fls.107/108).

Por ocasião da audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls.56/59). Às fls. 60/61, apontou-se que o presente feito seguiria o rito comum ordinário, previsto no art. 396 e ss. do CPP, porquanto mais amplo, inexistindo qualquer prejuízo à douta Defesa. Na ocasião, porquanto preenchidos os requisitos legais, foi recebida a denúncia e determinou-se a citação do inculcado. Citado, o réu apresentou resposta à acusação por intermédio de defensora dativa (fls. 109/132). Não sendo o caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 148/150). Foi encartado aos autos o laudo pericial toxicológico realizado no entorpecente apreendido (fls.103/106).

Na solenidade, iniciados os trabalhos, foi realizada a oitiva da testemunha arrolada em comum pelas partes, policial militar Paulo Rogério Casemiro, bem como foi interrogado o réu. Então, rumou o feito para os debates orais, em vista da inexistência de diligências complementares. Nos debates, a acusação protestou pela integral procedência da denúncia, ao passo que a defesa requereu a absolvição do acusado, sob a égide da anemia de provas.

É o breve relato dos autos (artigo 381, incisos I e II, do Código de Processo Penal). FUNDAMENTO e DECIDO.

Trata-se de ação penal manejada pelo Ministério Público com o fito de obter a condenação do acusado Gustavo Guerra nas sanções do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

PRELIMINARMENTE:

Embora o quanto dito pelo réu nesse particular, observo que o Julgador não está obrigado a determinar a realização do exame de dependência toxicológico se outros elementos de convicção vêm a justificar sua dispensa. O próprio Supremo Tribunal Federal assim tem assentado:

"cabe à autoridade judiciária avaliar necessidade de realização do exame pericial de dependência toxicológica, quando o réu é comprovadamente viciado ou quando há indícios desta condição, não constituindo cerceamento de defesa o indeferimento devidamente justificado" (HC 78.440/9-RJ).

Vale dizer, o simples fato de o réu ter alegado, quando de sua oitiva, ser usuário de drogas, não impõe a obrigatoriedade de realização do exame referido (STJ; HC 47293; J. em 19.12.05). E, no caso dos autos, durante a presente solenidade, o réu demonstrou clareza de raciocínio e higidez mental.

NO MÉRITO:

A materialidade da narcotraficância encontra-se sobejamente evidenciada por intermédio do auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), auto de constatação prévia de entorpecente (fl. 16/17), e, principalmente, por meio do laudo toxicológico de fls. 103/106, oportunidade em que concluíram os experts tratarem-se as substâncias apreendidas de 142,7g de cocaína e 252,8g de tetrahidrocannabinol. A autoria do acusado, da mesma forma, malgrado o louvável esforço da defesa, ressuma igualmente caracterizada pela prova testemunhal produzida.

Quando de seu interrogatório realizado em solo policial (fl. 08) e em Juízo, o acusado confessou os fatos, esclarecendo que, por estar em dívida com um traficante, no momento dos fatos, passou a trabalhar como "campana" em prol do comércio ilícito de entorpecentes, em frente à favela da Chácara das Tâmaras. Salientou que, nesse local, um sujeito lhe propôs "que pegasse 'dois paus' em troca de R\$10,00". Assim, atendendo ao pedido, pegou as drogas conhecidas como maconha e cocaína e, no trajeto de volta para a biqueira, foi abordado pela Polícia Militar.

É claro que a confissão do réu, por si só, não é fundamento suficiente para lastrear sua condenação, devendo vir amparada em outros elementos de prova. Vale dizer, conforme artigo 197 do Código de Processo Penal:

"o valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância."

Pois bem, no caso dos autos, realizado o referido cotejo, revelou-se inarredável coerência entre as palavras do acusado e as demais provas amealhadas.

O Policial Militar Paulo Rogerio, em seu depoimento prestado em solo policial (fl. 04) e em juízo, alinhavou que na fatídica data entrava-se em serviço, acompanhado do policial Rafael Coelho, em sua viatura, durante operação de Força Tática ao combate de tráfico de drogas, na Rua Manoel Francisco Lisboa. Em um determinado momento, visualizaram um indivíduo portando uma sacola de cor preta e uma mochila em suas costas, o qual tentou se evadir pelo beco ao notar a presença dos policiais, todavia foi alcançado e capturado. Revistada a mochila, encontraram os entorpecentes descritos na denúncia.

Estes, em linhas gerais, foram os mesmos fatos articulados pela policial Rafael, em seu depoimento prestado em solo indiciário (fl. 06/7).

É cediço que o valor do depoimento policial, inexistindo má-fé, constitui importante elemento de prova, o qual merece confiança, pois realizado após compromisso e sem contradita da parte do réu. Aliás, sobre a validade dos depoimentos dos policiais, relembre-se que:

"o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF - 1ª Turma - HC 74.608-0/SP - Rel. Min. Celso de Mello - DJU de 11.04.97, pág. 12.189).

Em outras palavras, segundo os milicianos, durante patrulhamento de rotina abordaram o acusado e encontraram, com ele, os entorpecentes apreendidos,

aconicionados em uma pochete preta. Relataram que, além de diversos entorpecentes, o réu trazia consigo R\$86,00 e uma folha com anotações alusivas à venda proscrita.

Estas são as provas. Diferentemente do que pretende fazer crer a defesa, entendo assistir razão à acusação na imputação de tráfico que é ofertada ao réu. É que a quantidade da droga encontrada (total de 142,7g de cocaína e 252,8g de tetrahidrocannabinol – fls 103/106) e as circunstâncias que envolveram o caso (apreensão de dinheiro), transparecem a finalidade comercial própria do tipo penal.

Observe-se ainda que os entorpecentes apreendidos já se encontravam em pequenas porções, adrede preparados para venda, e que a abordagem fora realizada após a atitude suspeita esboçada pelo acusado. Veja-se que os depoimentos prestados pelos policiais mostraram-se harmônicos, incluindo neles a confissão do réu na abordagem, sendo, ainda, secundados pela apreensão de entorpecentes.

Todo o contexto da situação flagrancial não deixa dúvidas acerca da conduta ilícita cometida pelo acusado. De resto, não se pode imaginar razões que justifiquem a alegação de estarem os policiais a acusar um desconhecido da prática de um delito, quando isso não ocorreu, unicamente para atender a algum sentimento íntimo sádico de culpar terceiros.

Diga-se de passagem, oportuno lembrar que:

"o crime de tráfico de entorpecentes compreende dezoito ações identificadas pelos diversos verbos ou núcleos do tipo, em face do que tal delito se consuma com a prática de qualquer delas, eis que delito de ação múltipla ou misto alternativo" (STJ; HC 27704/MS; Sexta Turma; Min. Rel. Hamilton Carvalhido; J. em 09/05/2006). E ainda:

"considera-se consumado o tráfico quando evidenciada o estado de flagrância em quaisquer de seus núcleos, ou seja, no momento da importação ou exportação, do depósito ou do transporte, de trazer consigo ou da guarda do entorpecente." (STJ; HC 34374/MS, Min. Gilson Dip p; Quinta Turma; DJ 01/07/2004).

Em resumo, encontra-se, pois, o acusado incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

DA PERDA DOS BENS:

Pela legislação em vigor, são três os tipos de bens que podem ser apreendidos: a) produtos do crime (artigo 60): vantagem direta obtida com a prática criminosa. Ex: o dinheiro recebido com a venda da droga; b) proveito auferido (artigo 60): é a vantagem indireta, conseguida a partir do produto, v.g., um carro comprado com a venda da droga; c) veículos, embarcações, aeronaves, maquinários, instrumentos e objetos de qualquer natureza, utilizados para a prática de crimes previstos na Lei (artigo 62).

Ademais, acentua a doutrina mais judiciosa que para a decretação da perda dos bens e valores apreendidos, mostra-se necessária a demonstração do nexu etiológico a os unir com o crime apurado.

Dito isso, tenho ser o caso de se decretar o perdimento do dinheiro (R\$ 86,00, fls. 14/15) apreendido. Como se sabe, o tráfico conta com um mínimo de aporte para facilitar a mercancia da droga. Restando, pois, demonstrada a conduta criminosa, caberia ao réu indicar a origem do dinheiro, o que em nenhum momento se prestou a fazer.

DOSIMETRIA:

A culpabilidade, entendida como grau de censura contida na ordem jurídica para

reprovação da conduta do réu, deve ser considerada normal. O acusado não é possuidor de antecedentes criminais. Sobre a conduta social e a personalidade do acusado não foram amealhados elementos suficientes nos autos. Os motivos e as circunstâncias são próprios à espécie. As consequências do crime foram normais. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito.

Diante destas circunstâncias judiciais, aplico a pena-base ao réu em seu mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor, cada um, de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do artigo 43 da Lei n. 11.343/06.

Ausentes quaisquer agravantes. Presente, por outro lado, a atenuante da confissão espontânea, ex vi do art. 65, inc. III, 'd', do CP (vide interrogatório colhido em Juízo), bem como aquela relativa à menoridade, conforme art. 65, inc, I, do CP, deixo de atenuar a pena até seu limite mínimo.

Ausentes quaisquer causas de aumento e de diminuição, inclusive a prevista no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas. Considerando a expressiva quantia de entorpecente apreendida, deixo de operar a diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas. É que tais circunstâncias revelam séria incursão da parte acusada na criminalidade, inculcando neste Juízo seja ela dedicada a atividades criminosas.

Não é preciso dizer muito para se compreender que a aquisição de tamanha quantidade de entorpecente não se dá com qualquer indivíduo, notadamente com o pequeno traficante. A perda da droga enseja inegável prejuízo, razão pela qual, no mundo do crime, exige-se responsabilidade de quem a transporta. Assim, se logrou a parte acusada assim agir, é porque está inserida na senda delitiva, não fazendo jus, portanto, à redução reclamada pela defesa. A este respeito, observo que:

"o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base quanto na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da nova Lei de Drogas" (STJ; HC 163495/SP; Rel. Min. Laurita Vaz; DJe 19/10/2011).

Ademais, consoante relatado pelo próprio acusado em seu interrogatório, ostenta condenação perante o Juízo da Infância e Juventude pela prática do ato infracional análogo ao crime de roubo, a descortinar, ainda mais, sua dedicação à atividades criminosas.

Inexistindo outras causas de modificação da pena, torno-a, destarte, em definitivo, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor, cada um, de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do artigo 43 da Lei n. 11.343/06.

Considerando que Supremo Tribunal Federal firmou entendimento acerca da inconstitucionalidade da fixação de regime inicial fechado para cumprimento de pena com base exclusivamente no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 8.072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos), deve o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal, não podendo fundamentar a fixação do regime inicialmente fechado unicamente em relação à hediondez do delito de tráfico de drogas.

A tese restou assim ementada:

"É inconstitucional a fixação ex lege, com base no artigo 2º, §1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal." (ARE 935.967 AgR; Rel. Min. Edson Fachin; Primeira Turma; J.:15.03.2016)

Desse modo, os critérios para a fixação do regime prisional inicial devem-se harmonizar com as garantias constitucionais, sendo necessário exigir-se sempre a fundamentação do regime imposto, ainda que se trate de crime hediondo ou equiparado. Vale ressaltar que tais circunstâncias não elidem a possibilidade de o magistrado, em eventual apreciação das condições subjetivas desfavoráveis, vir a estabelecer regime prisional mais severo, desde que o faça em razão de elementos concretos e individualizados, aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do §3º do art. 33, c.c art. 59 do Código Penal.

Na espécie, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, tendo em vista a confissão do acusado acerca dos fatos, bem como sua primariedade, ex vi do art. 33, §2º, 'b', e §3º do CP.

A possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por outras restritivas de direito há de ser analisada sob o prisma do artigo 44 do Código Penal.

Conquanto expressa a vedação acerca da aplicação do instituto aos casos de tráfico, tal qual se depreende dos arts. 33, §4º, e artigo 44, ambos da Lei n. 11.343/06, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Habeas Corpus n. 97256, publicado em 16/12/2010, cujo relator foi o Min. Ayres Brito, em controle difuso de constitucionalidade, concedeu a segurança pretendida para:

“remover o óbice da parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, assim como da expressão análoga 'vedada a conversão em penas restritivas de direitos', constante do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal.” E isso por se entender que “o processo de individualização da pena é um caminhar no rumo da personalização da resposta punitiva do Estado, desenvolvendo-se em três momentos individuados e complementares: o legislativo, o judicial e o executivo. Logo, a lei comum não tem a força de subtrair do juiz sentenciante o poder-dever de impor ao delinqüente a sanção criminal que a ele, juiz, afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo. Implicando essa ponderação em concreto a opção jurídico-positiva pela prevalência do razoável sobre o racional; ditada pelo permanente esforço do julgador para conciliar segurança jurídica e justiça material”.

Ademais, em 15/02/2012, o Senado Federal, valendo-se da prerrogativa que lhe é dada pelo art. 52, inc. X, da Constituição Federal, editou a Resolução n. 5, suspendendo a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.

Ainda que a Resolução editada pelo Senado Federal tenha se limitado a suspender a restrição existente somente no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, forçosa é a extensão de sua leitura também para a redação dada ao art. 44 do mesmo diploma, quando veda o mesmo benefício. É que o precedente jurisprudencial que motivou a edição da Resolução referida entendeu por inconstitucional tanto a vedação contida no art. §4º do art. 33 como também a do art. 44, ambos da Lei n. 11.343/06.

Todavia, mesmo que assentadas tais premissas, as circunstâncias do caso indicam não ser recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito ou, ainda, a suspensão condicional de sua execução. Como já positivado, foram encontradas mais de uma espécie de entorpecente, o que revela nocividade em seu comportamento, não compatível com a branda possibilidade de concessão dos benefícios referidos (artigo 44, inciso III, e artigo 77, inciso II, ambos do Código Penal).

DIANTE DO EXPOSTO:

JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA e, em consequência, CONDENO o acusado GUSTAVO GUERRA ANTONIO, já qualificado, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (CINCO) ANOS RECLUSÃO, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, no valor, cada um, de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 43 da Lei n. 11.343/06. Isto por considerá-lo incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Deixo de condenar o réu em custas processuais, porquanto defendido por defensora nomeada.

Por estarem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, ante os fundamentos elencados na decisão de fls. 56/59, não reconheço ao acusado o direito de recorrer em liberdade, recomendando-se-o no ergástulo em que se encontra até o trânsito em julgado (artigo 387, §1º, c/c artigo 312, ambos do Código de Processo Penal).

Deixo de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, por entender incompatível tal estipêndio com o crime apurado, dada a natureza difusa das vítimas.

Decreto a perda em favor de entidade beneficente cadastrada neste Juízo do dinheiro apreendido (vide fls. 14/15, R\$ 86,00).

Transitada em julgado, adote-se as seguintes medidas:

- i) em cumprimento ao art. 72, § 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o Colendo Tribunal Regional Eleitoral da circunscrição de residência do(s) condenado(s), dando-lhe ciência da condenação, para cumprimento do inciso III do art. 15 da Constituição Federal;
- ii) oficie-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD) dando-lhe conhecimento ao resultado deste julgamento;
- iii) expeça-se guia de execução (ou de recolhimento), provisória ou definitiva, conforme o caso, para o devido encaminhamento do(s) condenado(s) ao estabelecimento prisional estabelecido nesta sentença;
- iv) expeça-se a competente certidão de honorários, em valor fixado no máximo constante da tabela do Convênio;
- v) Transfira-se para entidade beneficente o dinheiro apreendido (fls. 14/15, R\$ 86,00).
- vi) Desde logo, não havendo interesse em recorrer, sai a parte acusada intimada para pagamento da taxa judiciária, se houver, no prazo de 10 dias. Sem prejuízo, extraia a serventia certidão de sentença a respeito da pena de multa imposta, abrindo-se vista ao Ministério Público.

Registre-se. Cumpra-se. Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Comarca de Itanhaém, 21 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA